

1500160-18.2022.8.26.0571

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora. Precedentes.x (RHC 35.920/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 29/05/2014). Certo, por tudo quanto consta nos autos, que o réu perpetrou o fato típico descrito na exordial, não incorrendo em hipóteses de exclusão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500160-18.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2027527/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 22734652 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 237/22/609 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2027527 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

GUILHERME TOMAZ

Artigo da Denúncia:

Art. 155 § 4º, I, IV ambos c/c Art. 14, II c/c Art. 61 "caput", II, "j" c/c Art. 69 "caput" todos do(a) CP(Denúncia)

Data da Audiência:

06/04/2022

Réu Preso

Em 06 de abril de 2022, às 15:00h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM^a Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: o representante do Ministério Público, na pessoa do DR. CARLOS EDUARDO POZZI, DD. Promotor de Justiça da Comarca de Tatuí, o réu GUILHERME TOMAZ, bem como o seu Defensor Técnico, DR. Ari Villa Nova Neto OAB 292980/SP. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual as testemunhas Cicero Jose Paciencia, EDNEIA CRISTINA VIEIRA DA ROCHA, Reinaldo Donizette Ribeiro e LUIZ CARLOS DE LIMA - Representante Legal OI MÓVEL S/A. INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de o acusado se entrevistar reservadamente com o seu Defensor. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas acima mencionadas, passando-se ao interrogatório do réu. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MM^a Juíza de Direito, eis que as partes não solicitaram que as inquirições fossem por elas iniciadas. Em razão da suspensão dos

trabalhos presenciais nos prédios do Tribunal de Justiça de São Paulo, como forma de prevenção e contenção do Covid-19 (Provimento nº 2545/2020 do Conselho Superior da Magistratura), a presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio audiovisual, através da plataforma Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, com o armazenamento dos arquivos digitais conforme determinado no Comunicado CG nº 1350/2020. Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. O réu GUILHERME TOMAZ, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado criminalmente como incurso no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, c.c. art. 14, inciso II, na forma do art. 69, esses do Código Penal, eis que: 1) no dia 31 de janeiro de 2022, por volta das 11h02, nas dependências da empresa de telefonia "OI", localizado na Avenida Donato Flores, nº 700 - Bairro Donato Flores, nesta cidade e Comarca de Tatuí, previamente ajustado, agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidade de propósitos com Jonas Araújo de Lima (desmembrado o processo em relação a esse agente - fls. 141), tentou subtrair, em proveito comum, mediante rompimento de obstáculo, 12 unidades de bateria automotiva modelo 12MF105 AMPER e 4 unidades de bateria modelo 12MF100, ambas da marca "Moura", pertencente à empresa vítima, ora representada por Luiz Carlos de Lima, não se consumando o furto por circunstâncias alheias à sua vontade; e 2) nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, agindo em concurso com Jonas Araújo de Lima, traziam consigo, para consumo pessoal, 2 porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 6,33 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo consta na exordial, na data dos fatos, o acusado e Jonas deliberaram pela prática de um furto e, nesse intuito, deslocaram-se até a empresa "OI" de telefonia a bordo do GM Onix, Placas EGJ-3086/São Paulo (SP), levando com eles uma mala contendo ferramentas diversas. No local, o acusado e seu comparsa destruíram o cadeado que fechava o acesso a uma torre de transmissão, ganharam as dependências da empresa, de lá subtraíram 16 baterias que estavam instaladas na mencionada torre (pertencentes à "Oi" e à empresa "Sky") e colocaram tudo dentro do veículo Onix, que estavam usando para praticar o crime. Ocorre que Luiz Carlos, funcionário da empresa - que estava trabalhando em "home office" - recebeu alerta de "alarme de porta aberta" na estação de Tatuí, efetuou contatos e verificou que havia furtadores no local. Diante disso, ele entrou em contato com o proprietário de um "ferro velho" que funcionava ao lado da "OI" (Cícero) que, por sua vez, visualizou GUILHERME e Jonas dentro da torre de telefonia e acionou a GCM. Assim é que, acionados, ao Guardas Civis compareceram no local e lá surpreenderam GUILHERME e Jonas na posse dos bens, com as baterias dentro do veículo Onix, sendo ambos abordados antes que lograssem deixar o local, razão pela qual o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos autores. Na ocasião, os Guardas verificaram que o acusado e seu comparsa haviam estourado o cadeado de acesso à torre e apreenderam o objeto danificado. Durante as diligências, em revista pessoal, os Guardas ainda encontraram 2 porções de "maconha" em poder de GUILHERME e de Jonas, drogas que lhes pertenciam e estavam destinadas ao consumo pessoal. A denúncia foi recebida 10 de fevereiro de 2022, oportunidade em que o feito foi desmembrado em relação a Jonas (fls. 140/141). O réu foi citado pessoalmente (fls. 169) e a Resposta à Acusação foi apresentada (fls. 177). Durante a instrução criminal, foram ouvidas a vítima e três testemunhas, sendo, ao final, interrogado o réu, tudo gravado em audiovisual. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia, enquanto a Defesa, ao revés, pugnou pela absolvição do réu, sustentando insuficiência probatória ou, subsidiariamente, atipicidade material dos fatos. Folha de Antecedentes a fls. 63/64, bem como certidão a fls. 65/66. É o relatório. Fundamento e Decido. Pois bem, o pedido

acusatório merece ser julgado procedente, pois a prova dos autos demonstra claramente a prática dos delitos narrados na exordial, o quais se mostraram consumados, não havendo dúvidas quanto à autoria, sendo patente a tipicidade da conduta. A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/07), pelo auto de avaliação (fls. 12), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 08/11), pelos laudos periciais de fls. 155/166 e, finalmente, pela contundente prova oral produzida. A autoria, por sua vez, é certa e inequívoca. Com efeito, em solo policial (fls. 20/21), o réu afirmou que o reside em São Bernardo do Campo e que está difícil de sustentar sua família, mesmo sendo eletricitista. Na noite de ontem, recebeu um convite de um amigo, de nome Jonas, para fazer um "serviço em Tatuí", para fazer a manutenção de baterias da rede de telefonia, inclusive, a operadora era NEXTEL. Segundo o seu amigo Jonas, o serviço era "legal", sendo assim, aceitou o convite, pois está precisando de dinheiro para sustentar a família. Nesta manhã, na companhia do seu amigo Jonas, vieram para a cidade de Tatuí. Jonas estava conduzindo o veículo dele, da marca GM/Onix e, nesta cidade, foram até uma torre de telefonia, que fica nos fundos de um desmanche. No portão principal da torre, o seu amigo Jonas abriu o cadeado de "segredo". Jonas tinha a senha deste cadeado e, após a abertura, entraram na torre e constataram que o container da Nextel estava "vandalizado". Então, começou a pegar as "baterias de telefonia" para fazer a manutenção e, segundo o interrogado, no local, havia dezesseis baterias utilizadas pelas empresas de telefonia. As baterias foram colocadas dentro do veículo GM/Onix, que é de propriedade de seu amigo Jonas. Quando estava tudo carregado, foram abordados por Guardas Cíveis e, no local, falaram com os Guardas que estavam fazendo manutenção e precisavam retirar as baterias. Havia uma denúncia que eles estavam "roubando". Confirmou que os Guardas Cíveis encontraram "um cigarro de maconha e um pequeno pedaço da mesma droga" e que era para o seu uso e do amigo Jonas, acrescentando que era uma pequena quantidade somente para o uso. Afirmou que somente veio para Tatuí a convite de Jonas, para fazer um serviço de manutenção, contudo, após a abordagem dos Guardas Cíveis, tomou conhecimento que estava cometendo o crime de furto. Quer deixar claro que somente veio para Tatuí para fazer um serviço de manutenção. Faz serviços esporádicos de eletricitista e nunca se envolveu nos meios policiais. Em juízo, o réu disse que a maconha era para seu consumo e confessou a prática dos fatos narrados na denúncia. É eletricitista, com renda mensal de R\$2500,00. Tem um filho e sua esposa está grávida do segundo. Analisando a autodefesa do acusado - colhida com máxima observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa - o réu confessou integralmente os fatos. De fato, Luiz Carlos de Lima, em solo policial (fls. 16), afirmou que é funcionário da empresa Oi Móvel S/A e que trabalha na empresa como técnico em telecomunicações. Na data dos fatos, estava em sua residência pois trabalha em "home office" e que um outro funcionário da empresa, que é responsável pelo setor de monitoramento de alarmes instalados, constatou que o site caiu e, antes de cair o alarme, reportou furto de bateria e porta aberta. Como referido funcionário tinha o contato do proprietário do terreno onde fica um ferro velho, ligou e perguntou para o dono do terreno se havia pessoas na estação rádio base. Então o proprietário do terreno relatou que havia um veículo no local com dois indivíduos e o funcionário pediu para que o proprietário do terreno acionasse a polícia. A guarda municipal foi até o local e confirmou a presença de sujeitos e os conduziu até a unidade policial. Em solo policial, reconheceu

que as baterias apreendidas eram da empresa Oi, pois são identificadas por numeração, um carimbo da Oi gravado ao lado das baterias, nas laterais. O cadeado estourado pertence a empresa Oi e que tem trava/fecha uma gaiola onde ficam as baterias, o qual também foi arrombado para acesso as baterias. O valor das baterias da empresa Oi é de R\$ 550,00 cada unidade, totalizando um prejuízo de R\$ 6.600,00. No local não há câmeras de monitoramento. Desconhece os furtadores e que não são funcionários e ou prestadores de serviço da empresa Oi. Em juízo, disse que é representante da vítima e um funcionário verificou um alerta de furto disparado, falaram com um indivíduo que morava no terreno e souberam que havia duas pessoas na estação, sendo que não havia nenhum funcionário autorizado para estar ali. Foi até

a delegacia e reconheceu as baterias. No local há uma gaiola de proteção com cadeado e só os funcionários tem a chave. Esse cadeado foi arrombado. Ademais, a testemunha Cícero José Paciência, em solo policial (fls. 14), afirmou que é proprietário do estabelecimento comercial denominado "Desmanche Paciência", cujo imóvel é locado e fica localizado à Avenida Flores, número 700, no bairro Donato Flores. Nesse mesmo terreno, há uma torre de telefonia da empresa OI e, na data dos fatos, recebeu um telefonema de um representante da referida empresa de telefonia. Naquele momento, o representante fez uma indagação, lhe perguntando se "havia alguém dentro da torre". Sendo assim, atendendo a solicitação do funcionário da empresa OI, ainda no seu quintal, pode "visualizar dois homens desconhecidos que estavam dentro da torre de telefonia" e, de imediato, ainda com o telefone nas mãos, informou ao representante da telefonia OI, o qual disse que "já havia solicitado o apoio da Polícia". Inclusive, o funcionário da empresa OI, disse que "aqueles homens estavam furtando bateria da torre". Naquela ocasião, viu que estava passando uma viatura da Guarda Civil Municipal e, por segurança, resolveu acioná-los, pois tinha a informação que aqueles dois homens estavam cometendo "furto de bateria", conforme o que havia dito o representante da telefonia OI. Os Guardas Civis abordaram os dois homens que estavam dentro da torre, inclusive, os Guardas localizaram várias baterias dentro de um carro GM/Onix, de cor branca. Esclareceu que os dois homens apresentados na Delegacia eram os mesmos que estavam dentro da torre. Em juízo confirmou os fatos já declarados em solo policial - disse que o representante da vivo tem seu telefone, pois tem um estabelecimento no terreno em que fica a torre. E o funcionário perguntou se tinha alguém mexendo ali e ele viu que tinha, sendo que o funcionário da vivo acionou a polícia e que seriam indivíduos furtando baterias. Outrossim, a Guarda Civil Municipal Edneia Cristina Vieira da Rocha, em sede policial (fls. 13), afirmou que, na data dos fatos, juntamente com seu parceiro, foram acionados para ocorrência versando sobre furto. No caso, o gerente de uma empresa destinada ao comércio de peças de veículo entrou em contato noticiando que pessoas desconhecidas, utilizando um veículo GM/ONIX de cor branca, estariam subtraindo objetos pertencentes à empresa OI de telefonia. Assim, realizadas diligências no local mencionado, efetivamente surpreenderam 02 (duas) pessoas que foram identificadas como GUILHERME TOMAZ e Jonas Araujo Lima fazendo a subtração de baterias, estas utilizadas em uma torre de transmissão. Os agentes foram surpreendidos já com as baterias no mencionado veículo. Sobre o local, eles romperam um cadeado para ter acesso ao delito. Ainda, inicialmente eles informaram que eram funcionários de uma empresa terceirizada da Anatel. Por fim, na posse deles, foi encontrada uma pequena quantia de substância aparentando ser maconha. Instados informalmente, os detidos confessaram o delito. Em juízo, disse que estavam em patrulhamento quando foram informados de um possível furto por indivíduos que se diziam funcionários mas não eram. Foram até o local apontando e os indivíduos estava colocando baterias em um veículo e disseram que eram funcionários de uma empresa, sem entretanto apresentarem qualquer documentação. No local foi encontrado um cadeado rompido, pertencente ao local em que estavam as baterias. Convergingo em mesmo sentido, o também Guarda Civil Municipal Reinaldo Donizetti Ribeiro, em sede policial (fls. 15), corroborou integralmente a versão de sua colega de corporação. Em juízo, a testemunha disse que estavam patrulhando na redondeza e em certa rua um veículo os abordou, o condutor disse que tinha um comércio de desmanche e que no fundo tem uma torre de telefonia e que havia duas pessoas mexendo no painel e a empresa Oi entrou em contato com ele perguntando se havia alguém mexendo na torre e ele disse que sim que pensava ser funcionária. A empresa disse que não era funcionário e pediu que ele chamasse a polícia. Foram ao local, encontraram dois indivíduos, colocando baterias num carro branco. No começo começaram a enrolar que eram funcionários, mas não apresentaram nenhum documento. Os indivíduos estavam colocando a bateria no porta-malas. As ferramentas estavam dentro do veículo, bem como a porção de maconha. Eles disseram que as ferramentas eram para o trabalho e a maconha para uso próprio. Averiguou que havia um cadeado rompido, no chão e indagou isso aos indivíduos. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus

testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos guardas, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente o réu ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu, Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). Diante do arcabouço probatório emergente dos autos, é inequívoco que o acusado tentou furtar o bem da vítima, conforme: 1) declarações do funcionário da ofendida, afirmando que notou o acionamento dos alarmes do local e solicitou a presença dos agentes de segurança, bem como afirmando que houve rompimento de dois cadeados para acesso ao local e reconhecendo os bens apreendidos com o acusado e Jonas como sendo da vítima; 2) os depoimentos dos guardas, confirmando que encontraram o réu no local dos fatos com a res furtivae; 3) o depoimento de Cícero, confirmando que o réu e Jonas eram as pessoas que viu no local dos fatos e 4) a confissão do réu. As qualificadoras de rompimento de obstáculo e concurso de pessoas também restaram devidamente demonstradas. Isso porque a prova oral revelou que o acusado agiu juntamente com Jonas para realizar a prática criminoso, bem como que acessou o local danificando o cadeado que selava o local, o que foi corroborado pelo laudo pericial de fls. 164/166, o qual constatou que os cadeados estavam com suas respectivas hastes serradas (fls. 165/166). O crime restou configurado em sua modalidade tentada, porque o réu e Jonas iniciaram a execução do furto, ingressando no local e amealhando a res furtivae, mas não obtiveram o resultado criminoso pretendido (subtração das baterias), o qual era possível, pela competente ação da Guarda Civil Municipal, que os surpreendeu no local dos fatos com os bens da ofendida. Inaplicável o princípio da insignificância, na medida em que se trata de furto duplamente qualificado e o valor do bem, avaliado em R\$ 10.600,00 (fls. 12), não é ínfimo. Do mesmo modo, inviável a incidência da figura do furto privilegiado, de que trata no art. 155, § 2º, do CP. Ora, a res furtivae era valiosa, avaliada em R\$ 10.600,00 (fls. 12), não se amoldando ao conceito de "coisa de pequeno valor". E, portanto, não estando presente o requisito objetivo do furto privilegiado, inaplicável essa benesse legal. Igualmente evidente é que o acusado foi encontrado com entorpecentes, os quais eram destinados ao seu consumo, conforme: 1) depoimentos dos agentes de segurança, confirmando que, com o réu e seu comparsa, foi encontrada a droga apreendida; 2) a confissão do acusado, de que possuía o entorpecente e que esse seria destinado ao seu consumo; e 3) o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 160/163, que comprova que a substância apreendida era droga, da espécie cocaína. Tipificado, pois, o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Isso tanto no aspecto formal, subsunção fato praticado com a norma penal incriminadora, mas também materialmente, isso é, sem incidência do princípio da insignificância. Ora, a pouca quantidade de droga é requisito que auxilia na configuração do tipo penal em questão (art. 28, § 2º, da Lei de Drogas). Isso é, é praticamente inerente ao crime em questão a pouca quantidade de droga. E, assim, reconhecer que a pouca quantidade de droga é fundamento para não tipificação material do crime implicaria, obliquamente, em revogação tácita do tipo penal em questão, providência que não cabe ao Poder Judiciário. A propósito, assim entende o

C. STJ: "Independentemente da quantidade de drogas apreendidas, não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora. Precedentes.x (RHC 35.920/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 29/05/2014). Certo, por tudo quanto consta nos autos, que o réu perpetrou o fato típico descrito na exordial, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou culpabilidade, emerge-se o jus puniendi, razão pela qual passo a dosar a pena a lhe ser imposta. I – DO FURTO QUALIFICADO: Observando o disposto no artigo 59, caput, do Código Penal, saliento, de início, que os apontamentos criminais retratados a fls. 65/66, se referem a ações penais em curso e, a despeito de entendimento pessoal diverso dessa Magistrada, observo que a jurisprudência se consolidou no sentido da imprestabilidade desses registros delitivos como maus antecedentes ou para a valoração negativa em primeira fase (Súmula nº 444 do STJ). Aliás, assim também tem se posicionado a jurisprudência do E. TJSP, apontado que ações penais em curso, ainda que condenações provisória: "embora tal circunstância denote a personalidade desregrada do acusado, não se presta a majorar a sanção inicial, a teor da Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça." (TJSP; Apelação Criminal 1502727-43.2020.8.26.0037; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araraquara - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/08/2021; Data de Registro: 03/08/2021). No entanto, tem-se que o réu praticou o crime com a incidência de duas qualificadoras (rompimento de obstáculo e concurso de pessoas). Diante disto, deve a primeira servir para alterar o patamar do preceito secundário do tipo simples para o qualificado e a outra como circunstância judicial. A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça permite, em caso de multiplicidade de qualificadoras, a consideração desta pluralidade em dosimetria da pena: "(...) 3. A dosimetria penal encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Casa a qual autoriza, diante da presença de dois elementos que qualificam o crime, que um deles seja utilizado para a tipificação e, outro, como circunstância judicial desfavorável." (STJ - HC: 206427 SP 2011/0106484-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/08/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2011). Deste modo, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Em segunda fase, presente a atenuante da confissão, retorno a pena ao mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Por oportuno, convém destacar a inaplicabilidade da agravante do estado de calamidade pública. Ora, não há provas de que o acusado se valeu das fragilidades proporcionadas pela situação calamitosa ou que agravou esse estado. Assim, imperioso o afastamento da agravante postulada pelo Parquet. Aliás, assim se posiciona a jurisprudência: "Contudo, entendo que a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, relativa ao estado de calamidade pública, deve ter na sua incidência relação com o contexto do delito e a desproteção do bem jurídico tutelado pelo tipo penal. No entanto, no caso em apreço, entendo não comprovada relação direta entre o cometimento do delito e a emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus (declarada pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020), de modo que o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, em razão do crime ter sido praticado durante estado de calamidade pública, deve ser afastado. Note-se que não há qualquer evidência nos autos de que o estado de calamidade tenha facilitado a ação criminosa, de que o apelante tenha se aproveitado dessa situação excepcional para perpetrar o delito ou, ainda, de que o crime tenha sido mais grave por ter ocorrido durante a pandemia" (TJSP; Apelação Criminal 1501673-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021). Em terceira fase, considerando que fora o crime tentado, conforme previsto do art. 14, inciso II, do Código Penal, diminuo a pena dos réus em 1/3, patamar adequado ao iter criminis percorrido. De fato, quando da interrupção do crime, o acusado estava estágio final de execução de sua empreitada criminosa, pois já havia ingressado no local, amealhados os bens, restando, para a

consumação delitiva, apenas deixar o local em posse da res furtivae, o que não foi realizado pela diligente ação da Guarda Civil Municipal. Nestes termos, produz-se a reprimenda legal de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, a qual torno definitiva, ante a minguagem de demais causas modificadoras da pena a incidir. Fixo o dia-multa no mínimo legal e o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade no aberto. Presentes os requisitos legais, substituo sua pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito consistentes em: 1) prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas a serem determinadas pelo juízo da execução, na razão de uma hora por dia de condenação; e 2) prestação pecuniária, no valor de 01 salário-mínimo, a ser destinada a entidade pública oportunamente especificada pelo Juízo da Execução Penal. Por derradeiro, deixo de aplicar a regra da progressão antecipada (art. 387, §2º, do CPP), posto que a concessão desta medida dependa da análise de condições não exclusivamente objetivas, tal como o bom comportamento carcerário. Em assim sendo, não havendo nos autos informações sobre o cumprimento da pena, a viabilidade de concessão desta benesse restou prejudicada. Neste diapasão é o entendimento do E. TJSP. Vejamos: "No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei nº 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena". (TJSP, 16ª Câmara Criminal, Apelação n. 0016604-05.2011.8.26.0114, Rel. Des. ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, julgado em 04.06.2013).

II - DO PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO: Tendo em vista que se trata de réu que praticou outro crime além da figura criminosa em questão, com base no art. 27, c.c. art. 28, § 3º, ambos da Lei de Drogas, fixo cumulativamente as penas de prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (incisos II e III), pelo prazo máximo de 05 (cinco) meses.

III - DO CONCURSO MATERIAL: Considerando que os crimes praticados são autônomos e que foram perpetrados mediante condutas distintas, resta configurado o concurso material de crimes, reclamando a regra de cumulação das penas aplicadas. Não havendo incompatibilidade, é o caso de cumprimento simultâneo das penas aplicadas (art. 69, § 2º, do CP).

IV- DO DISPOSITIVO: Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o réu GUILHERME TOMAZ, devidamente qualificado nos autos, foi como incurso no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, c.c. art. 14, inciso II, na forma do art. 69, esses do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 06 (seis) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito consistentes em: 1) prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas a serem determinadas pelo juízo da execução, na razão de uma hora por dia de condenação; e 2) prestação pecuniária, no valor de 01 salário-mínimo, a ser destinada a entidade pública oportunamente especificada pelo Juízo da Execução Penal; sem prejuízo e cumuladas com as penas alternativas de prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (incisos II e III), pelo prazo máximo de 05 (cinco) meses. Defiro apelo em liberdade ao acusado, na medida em que, substituída sua pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não há qualquer razão para a privação de sua liberdade cautelarmente, com espeque no princípio da proporcionalidade.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLUTRA COM MÁXIMA URGÊNCIA. Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento e arquivem-se os autos. Deixo de fixar quantum mínimo indenizatório, já que não foi formulado oportuno pedido nesse sentido. Na hipótese de descumprimento injustificado da restrição imposta, a pena restritiva de direitos será convertida em pena privativa de liberdade, com início de cumprimento no regime aberto (art. 44, §§ 4º e 5º, art. 33, § 2º, "c", e § 3º, c.c. art. 59, III, todos do Código Penal, e art.110 da Lei de Execução Penal). Isento o acusado do pagamento das custas processuais, concedendo-lhes os benefícios da Justiça Gratuita, já que assistido por Defensor Dativo (fls. 170). Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor total de pena de multa. Após, intime-se o réu para que efetue o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Quanto aos bens apreendidos ainda não liberados, libere-os em favor dos legítimos proprietários, mediante comprovação de titularidade dos bens. Acaso transitado em

julgado e

decorrido o prazo de 90 dias sem que se reclame a liberação dos objetos, destrua-se esses na forma do que preceitua os arts. 123 e 124, ambos do CPP. Pelo Defensor do acusado foi dito que não tinha interesse em recorrer, notadamente porque o próprio réu manifestou desinteresse no recurso. A seguir pela MMª Juíza foi dito: "Homologo a desistência do prazo recursal em relação ao réu e determino a certificação do trânsito em julgado, tão logo decorrido o prazo para recurso do Ministério Público, então expedindo-se o necessário, inclusive certidão de honorários em favor do patrono nomeado (fls. 170), os quais arbitro em 100% do previsto sob o respectivo código, a ser pago integralmente pela Defensoria, uma vez que a não interposição de recurso decorreu de interesse do próprio réu. Saem os presentes intimados". Com o trânsito em julgado da condenação criminal, lance-se o nome do(a) réu no rol dos culpados. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA